

1500141-40.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... para a consumação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É certo também que a legislação antidrogas estabelece que, para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500141-40.2022.8.26.0594

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

FÁBIO BRITO JUNIOR

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

FÁBIO BRITO JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 5 de fevereiro de 2022, por volta de 0h30, na Praça Machado de Mello, nº 1-16, Centro, nesta cidade e Comarca de Bauru, foi surpreendido com 10,47 g de entorpecente conhecido como cocaína, divididos em 68 porções, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida às fls. 1/5.

A decisão de fls. 108/110 recebeu a denúncia e determinou a notificação e citação do réu.

O réu foi notificado (fl. 270) e apresentou defesa prévia às fls. 274/275.

A decisão de fls. 279/288 manteve o recebimento da denúncia e deu início à fase de instrução processual, procedendo-se à oitiva de três testemunhas comuns e ao interrogatório do réu (fls. 317/319-mídia).

Superada a fase de diligências, em alegações finais o representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, uma vez que entendeu provados os fatos narrados na denúncia, bem como a materialidade e a autoria delitivas (fls. 331/337).

Em outro ângulo, a Defesa pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e fixação de regime inicial diverso do fechado (fls. 341/347).

Por despacho de fl. 348, o julgamento do feito foi convertido em diligência para juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo, o que se deu às fls. 349/352.

A defesa reiterou seus memoriais (fl. 356) e o Ministério Público não se manifestou (fl. 358).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
DECIDO.

Trata-se de ação penal pública instaurada para a apuração do crime de tráfico de drogas.

O conjunto probatório é contundente e apto a dar arrimo à procedência da denúncia.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 6/8, boletim de ocorrência de fls. 35/37, auto de exibição e apreensão de fl. 40, laudo de constatação provisória de fls. 42/46, laudo toxicológico definitivo de fls. 349/352, bem como pela prova oral amealhada nos autos.

A imputação da autoria do delito ao réu é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

Em seu interrogatório, o réu confessou a prática criminosa. Disse que estava desempregado e passando por dificuldades financeiras, bem como sua companheira estava doente, quando então decidiu comercializar entorpecentes. Falou que foi abordado pelos policiais na porta do hotel, onde estava hospedado há três meses, e conduzido ao quarto, tendo sido localizadas porções de cocaína e a quantia de R\$ 300,00. Aduziu ser usuário de drogas e estar arrependido do delito (fls. 317/319-mídia).

O policial militar Edmar Roberto Biazotto relatou ter recebido solicitação oriunda da Base Policial situada na Praça Machado de Mello, região central da cidade, comunicando que um indivíduo conhecido como "Tato", hóspede do Hotel Imperial, estava comercializando drogas no local. Mencionou que no saguão do estabelecimento encontrou o réu, cujas características eram coincidentes com aquelas informadas, e procedeu à abordagem, localizando dinheiro em notas diversas. Acrescentou que havia um segundo indivíduo, chamado Fabrício, porém nada de ilícito com ele foi encontrado. Esclareceu ter conversado separadamente com ambos, sendo que a testemunha Fabrício informou ser usuário de drogas, há alguns dias frequentava o

hotel e momentos antes havia adquirido duas porções de cocaína do réu; ato contínuo, o réu admitiu a prática do tráfico de drogas. Asseverou que no quarto do réu foi encontrada uma bolsa contendo 68 porções de cocaína (fls. 317/319-mídia).

No mesmo sentido, o policial Paulo Sérgio Silvestrini contou que se dirigiu ao Hotel Imperial, situado nas proximidades da Base Policial da Praça Machado de Mello, e no saguão do estabelecimento abordou o réu e outro indivíduo chamado Fabrício, tendo sido encontrada a quantia de R\$ 300,00 em poder do réu. Explicou que a testemunha Fabrício admitiu que havia comprado duas porções de cocaína do réu, momento em que este confessou a mercancia e informou que armazenava o estupefaciente em seu apartamento, onde foi localizada uma bolsa contendo diversos eppendorfs de cocaína (fls. 317/319-mídia).

Por fim, a testemunha Fabrício Moura dos Santos falou que conhecia o réu do hotel onde ambos residiam. Negou ter dito aos policiais que havia comprado entorpecente do réu. Narrou que, no momento dos fatos, viu os policiais abordando o réu na porta do hotel, sendo que tentou sair do estabelecimento e foi impedido pelos militares, os quais vistoriaram seu quarto e nada foi encontrado; ato contínuo, os agentes entraram no apartamento do réu e disseram ter encontrado entorpecente no aposento. Esclareceu ser usuário de drogas e estar preso pela prática de furto (fls. 317/319-mídia).

Ao que se vê, as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e da apreensão dos entorpecentes, dão respaldo ao decreto condenatório.

As circunstâncias evidenciam a prática do delito nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, verbos nucleares trazidos pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, os policiais militares foram uníssonos e categóricos em afirmar como se deram os fatos, haja vista que receberam informação da prática de tráfico de drogas por um indivíduo no Hotel Imperial, localizado nas proximidades da Base Central da Polícia Militar, e no estabelecimento encontraram o réu, cujas características coincidiam com a notícia inicial, sendo que ele admitiu a mercancia ilícita e em seus aposentos foram apreendidas porções de cocaína.

A propósito, nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório dos depoimentos dos policiais, os quais mantiveram as mesmas versões em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência dos depoimentos dos agentes revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não podem ser desconsiderados os depoimentos dos militares, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos agentes, razão pela qual não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de pertencerem ao quadro da Polícia. Nesse sentido:

“Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da

fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes." (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018).

TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.

1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (STJ. HC nº 267.025 - DF. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do julgamento: 02 de maio de 2013) (destaquei).

Ora, diante de toda prova produzida e com riqueza de detalhes de como se deram os fatos, não há se falar em fragilidade do conjunto probatório a ponto de propiciar a absolvição do réu.

Da análise do boletim de ocorrência de fls. 35/37, do auto de exibição e apreensão de fl. 40, do laudo de constatação provisória de fls. 42/46 e do laudo toxicológico definitivo de fls. 349/352, é possível observar que foram apreendidos 68 eppendorfs de cocaína (10,47 g), além da quantia de R\$ 300,00, a corroborar o exercício da traficância.

Não fosse pela prova oral produzida, já tão suficiente à condenação, a quantidade e a forma como os produtos apreendidos foram encontrados encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.

Igualmente, para a consumação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É certo também que a legislação antidrogas estabelece que, para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente de drogas. A quantidade de droga apreendida tem sido referencial na jurisprudência brasileira para caracterização do ilícito da mercancia. Claro que não basta essa única circunstância. Todo conjunto probatório leva à responsabilização do réu. Nesse sentido:

[...] 5. Tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. O fato do réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque

tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ [...] (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001686-11.2011.8.26.0400. Relator: Des. Airton Vieira. Data do julgamento: 10 de outubro de 2017)

Por todo o exposto, entendo que o quadro probatório formado ao longo da instrução autoriza a conclusão do cometimento, pelo réu, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu não ostenta antecedentes criminais, a não ser a reincidência a ser considerada em momento oportuno. Nada foi apurado sobre a sua conduta social, assim reputo-a em seu favor. Com relação à personalidade, possível aferir que o réu afirma estar arrependido pelo delito, objetivando apresentar ingenuidade, contudo é reincidente específico no tráfico de drogas, demonstrando que apenas há arrependimento quando ocorre a prisão. Ainda, o fato de ser usuário de entorpecentes macula sua personalidade. Igualmente, nota-se que o réu, enquanto preso por este processo, fugiu de unidade hospitalar quando o Estado lhe dispensava atendimento médico, tendo sido capturado depois de um mês, na cidade de Ourinhos (fls. 100/104, 120/154 e 158/263). O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito não levam à exasperação da pena.

Destarte, havendo uma circunstância judicial contra o réu (personalidade), fixo a pena para esta fase no mínimo legal, acrescida de 1/5, resultando em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (fl. 53: processo nº 0003673-51.2014.8.26.0344). Dessa maneira, inviável, no caso concreto, a compensação integral entre ambas, tendo em vista se tratar de reincidência específica. Prepondera, pois, a agravante, com fundamento no artigo 67 do Código Penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPÇÃO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de ilegalidade no aumento da pena-base, tendo-se utilizado de uma condenação anterior, já extinta pelo cumprimento, como maus antecedentes e outra para o aumento pela reincidência. Ausente qualquer referência à utilização de condenação sem o devido trânsito em julgado. A ilegalidade apontada nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, deve estar demonstrada de plano, não se admitindo dilação probatória. 2. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de serem igualmente preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, não sendo viável, contudo, a compensação integral das mencionadas agravante e atenuante, quando se tratar de reincidência específica. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 415804 SP 2017/0231736-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018)

Assim, majoro a pena em 1/4, ficando, então, estabelecida no montante de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, destacando-se a aplicação de patamar menor (1/4) do que seria efetivamente adotado caso não houvesse a atenuante.

Por outro lado, não se pode admitir, in casu, a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Com efeito, o réu cometeu o delito em 5 de fevereiro de 2022 e mencionada agravante apenas deve ser considerada nos casos em que o infrator pratica o crime aproveitando-se de situação de desgraça particular ou calamidade

pública. Acerca da matéria, é de fundamental importância destacar a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

"[...] mais uma vez o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. Vale-se da fórmula genérica e depois dos exemplos específicos. Constituem os gêneros da agravante: a) calamidade pública: que é a tragédia envolvendo muitas pessoas; b) desgracia particular do ofendido: que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Como espécies desses gêneros temos o incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades públicas, ora desgracias particulares de alguém. Ex.: durante a inundação de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto os moradores buscam socorro" (Código Penal Comentado, 16. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Na hipótese dos autos, contudo, nada restou demonstrado no sentido de que o réu tenha se beneficiado ou aproveitado do contexto da pandemia para justamente praticar o delito, como também a calamidade pública do novo coronavírus enfrentada por toda população mundial em nada interferiu nas atividades criminosas do réu.

Assim, mantenho as sanções da forma como anteriormente fixadas.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena. Também não é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a reincidência do réu, bem como a nocividade e a quantidade de entorpecentes apreendidos (68 eppendorfs de cocaína), fato que revela a dedicação do réu a atividades delitivas, com a existência de uma estrutura voltada à prática da traficância. Dessa forma, ficam as penas mantidas em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

O regime inicial deverá ser o fechado (artigo 33, § 2º, "a" e "b", do Estatuto Repressivo), considerados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e a reincidência do réu. Ademais, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, dispõe que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas. Ainda, a fixação do regime fechado é imprescindível à prevenção e repressão do crime cometido, de modo a atender o princípio da suficiência da pena (artigo 59 do Estatuto Repressivo).

Por fim, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, é vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, além, é claro, do não atendimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o réu FÁBIO BRITO JÚNIOR à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época da infração para cada dia-multa, por violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da Constituição Federal).

Comprovada a origem ilícita do dinheiro apreendido (fl. 111), decreto o perdimento da importância em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006. Transitada em julgado, providencie-se a transferência do numerário para a conta do FUNAD e oficie-se à SENAD (artigo 63, § 4º, da Lei de Tóxicos).

Outrossim, decreto a perda da bolsa apreendida (fl. 40), devendo ser observado o disposto nos artigos 516 e 517 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

O réu respondeu ao processo custodiado. Assim, presentes os requisitos à segregação cautelar e não se alterando a situação dos autos, tanto mais diante desta decisão e da pena ora aplicada, bem como pela reincidência, além das razões já expostas às fls. 85/87, 279/288 e 322/329, indefiro-lhe o recurso em liberdade nesta fase processual. Recomende-se, pois, o réu na prisão onde se encontra.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA